

1500317-04.2021.8.26.0481

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Incitação ao Crime

Magistrado: BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... que foi constatado conversas indicando o tráfico de drogas.

Interrogado, o acusado RENAN DIAS FRANCISCO negou os fatos narrados na denúncia relacionados ao tráfico e incitação ao crime. Afirmou ser usuário de maconha. Sobre o delito de tráfico, disse que realmente quis tirar proveito da situação, porém, nunca conseguiu concluir nenhuma venda porque o seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

2ª Vara

Av. Presidente Vargas, 131, Presidente Epitacio-SP - cep 19470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500317-04.2021.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-04.2021.8.26.0481

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Incitação ao Crime

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2067812/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

PRES.EPITACIO, 16690006 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 2067812 - DEL.POL.PLANTÃO

PRES.EPITACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN DIAS FRANCISCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Vistos.

RENAN DIAS FRANCISCO, devidamente qualificado(a) às fl. 119 dos autos deste processo crime, foi denunciado como incurso nos artigos 28, caput, e 33, caput, da Lei nº 11.343/06, este c/c com artigo 71 do Código Penal; e, no artigo 286, caput, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do mesmo código, pois, segundo a denúncia, vendeu, em continuidade delitiva, quantidades indeterminadas de cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, nos termos da Portaria n.º 344/98 SVS/MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como também incitou, publicamente, a prática de crime e guardou, para consumo pessoal, uma pequena porção e oito "bitucas" de cigarro de "maconha", com peso aproximado de 10,1 g, substância que causa dependência física e psíquica, nos termos da Portaria n.º

344/98 SVS/MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (fls. 238/262 e 329/337).

A denúncia foi recebida em 16/02/2022 (fls. 540/543), oportunidade em que os autos foram desmembrados em relação aos réus ALMIR MENDES DE OLIVEIRA; KLEBER GONÇALVES BATISTA; GILMAR DANIEL FERNANDES RODRIGUES; DAVYD WANDER SILVA ARAÚJO e OBIDIEL MATEUS TOMAZ, prosseguindo-se somente em relação ao réu RENAN DIAS FRANCISCO.

Regularmente citado (fls. 571), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 583).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 593/596), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e, após, interrogado o acusado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Parcial razão assiste ao Ministério Público.

A materialidade do delito previsto nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06 está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. de fl. 121, bem como pelo exame químico toxicológico de fls. 254/256 e conversas de fls. 375/397.

Inconteste, também, a autoria, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado Renan Dias Francisco.

A testemunha MARCIO DOMINGOS FIORESE, Delegado de Polícia, asseverou que em fevereiro do ano passado foi divulgado um vídeo no youtube intitulado “na bala”, em que os integrantes do clipe faziam evidente incitação ao crime, notadamente consumo de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Mencionou que esse vídeo foi feito nesta cidade. Narrou que em razão do vídeo foi feita busca e apreensão na residência dos investigados, sendo dois residentes nessa cidade e os demais em Bataguassu/MS. Disse que com Renan foi apreendido um smartphone, porção de maconha e bitucas, indicando que seria para consumo pessoal, contudo, na perícia do celular foi indicado pelas mensagens de whatsapp, conversas indicando o comércio de drogas. Asseverou que, indagado, Renan disse que a arma mostrada no clipe seria um simulacro, bem como que Almir seria o idealizador do vídeo e que a intenção do vídeo era alertar sobre o tráfico.

A testemunha ANDREA PINHEIRO PEREIRA, policial civil, relatou que chegou ao conhecimento do setor de investigação que tinha um vídeo no youtube, onde Renan era o vocalista, de apologia ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas, etc. Narrou que identificaram os integrantes do grupo e cumpriram mandado de busca, sendo encontrado na casa de Renan algumas porções de drogas. Relatou que as armas exibidas no clipe não foram encontradas. Disse que não acompanhou as buscas na casa de Renan.

A Testemunha EVANIO DE SOUZA, policial civil aposentado, afirmou que participou do cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão, mas não se recorda se participou da busca na residência de Renan.

A testemunha VANDERLI JOSÉ FERREIRA DE PINHO, escrivão de polícia, relatou que tiveram conhecimento de um vídeo veiculado nas redes sociais em apologia ao crime de uso de drogas, tráfico de drogas, bem como desafiando a polícia e tal. Mencionou que foi feita busca e apreensão na residência dos investigados, e foi apreendido um celular na casa de Renan que foi constatado conversas indicando o tráfico de drogas.

Interrogado, o acusado RENAN DIAS FRANCISCO negou os fatos narrados na denúncia relacionados ao tráfico e incitação ao crime. Afirmou ser usuário de maconha. Sobre o delito de tráfico, disse que realmente quis tirar proveito da situação, porém, nunca conseguiu concluir nenhuma venda porque o seu fornecedor não tinha o entorpecente no momento e depois o comprador não queria mais. Quanto à imputação de incitação ao crime, relatou que seu colega Almir fez uma música e estava querendo um participante para gravação e na emoção aceitou. Disse não ter sido consultado para autorização de postagem do clipe no youtube e não sabia que seria postado em redes sociais, achou que fosse apenas “um vídeo entre amigos”. Esclareceu que foi o

vocalista da banda somente naquele dia.

Em relação à imputação do artigo 286 do Código Penal, sabe-se que para sua configuração é indispensável que o agente instigue pessoas determinadas ou indeterminadas da coletividade a praticar crimes específicos, pois se presente somente menção genérica a crimes, não haverá conduta típica.

No caso dos autos, não foi possível extrair da letra da música veiculada, qualquer ato de instigação ou incitação à prática de delitos específicos. Quando muito, faz menção a atos genéricos, mas sem extrapolar os limites da opinião, de modo que inviável invocar a tutela penal para coibir uma manifestação de pensamento.

De se destacar, pois, o necessário exercício de adequação da tutela penal com o das liberdades públicas individuais, dentre essas, a liberdade de expressão, definida na Carta Constitucional como a livre manifestação de pensamento (art. 5º, inciso IV)

Como já mencionado, a instigação vaga é ineficaz para caracterizar o crime previsto no art. 286 do Código Penal e, no caso aqui apreciado, não foi possível extrair nenhum conteúdo alusivo à prática de qualquer delito, sendo inviável o elastecimento semântico da música publicada a ponto de acomodar uma interpretação que traduza a estímulo ao tráfico, uso ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Assim, evidente a atipicidade da conduta descrita, praticada dentro dos limites da liberdade de manifestação de pensamento e sem qualquer conteúdo alusivo à prática de crimes, sendo de rigor sua absolvição.

É o que também entende o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INCITAÇÃO AO CRIME. COMENTÁRIO EM PÁGINA DO FACEBOOK. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO. INSTIGAÇÃO VAGA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Neste caso, o paciente foi acusado de ser o responsável por uma página no Facebook na qual se lia um comentário alusivo a possíveis ações da Polícia Militar em um bairro na cidade de Bauru. O comentário (A multidão organizada sempre colocou os cães do Estado para correr.) foi tipificado como crime, previsto no art. 286 do Código Penal. 5. O delito de incitação ao crime pressupõe, além da publicidade dos comentários de incentivo ao cometimento da infração penal, que seja possível extrair das palavras de estímulo referência a delitos determinados, pois a instigação genérica, por ser vaga, é ineficaz. 6. Na situação aqui debatida, não é possível extrair das palavras do comentário a incitação clara à prática de qualquer crime, sendo inviável o elastecimento semântico da frase a ponto de acomodar uma interpretação que possa ser traduzida como estímulo à prática de nenhum delito de modo específico. 7. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1511372-52.200.8.26.0071. (HC n. 659.499/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, STJ - Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

PROCESSUAL PENAL. SINDICÂNCIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO MANIFESTADO PELO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO PROSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS, DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA TIDA COMO DELITO DE INCITAÇÃO AO CRIME. ART. 286 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE OBJEÇÃO AO PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO. [...] 5. Pois bem, o delito previsto no art. 286 do Código Penal (incitação ao crime), necessita, para sua caracterização, que o crime alegadamente estimulado pelo agente seja claro, preciso, determinado, com todas as suas dimensões bem delineadas (ato típico e antijurídico), não se prestando o encorajamento genérico a determinada conduta caracterizador do delito. Assim, a forma genérica e ampla da narrativa do Governador representado deixa escapar a tipicidade do delito, imprescindível à inauguração de qualquer procedimento criminal. (...). 7. Para a configuração do delito previsto no art. 286 do Código Penal (incitação à prática de crime) é indispensável que o agente instigue pessoas determinadas ou indeterminadas da coletividade a praticar crimes específicos.

Assim, havendo somente menção genérica a crimes, não há conduta típica, devendo a sindicância ser arquivada.

Por outro lado, o contexto das provas produzidas é consistente em imputar ao réu a

prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, narrado na denúncia. O réu tentou se esquivar da responsabilidade ao declarar que nunca conseguiu concluir uma venda. Contudo, para a configuração do delito de tráfico de drogas em sua modalidade consumada, é dispensável que o agente conclua a comercialização propriamente dita, bastando a demonstração da materialidade e de elementos que indiquem o comércio ilícito, sendo desnecessária a tradição do entorpecente, consumando-se a conduta "vender", no momento do acordo de vontades, o que restou evidenciado nos autos.

Além dos elementos colhidos no momento do interrogatório, pelas conversas obtidas da apreensão do seu celular (fls. 367/389), também ficou demonstrada a patente comercialização de entorpecentes:

Em 02/02/21: o contato "Rael" pede para RENAN "20\$ no F. pra jaja"; Em 07/03/21: o contato "Rafael" pergunta se ele tem "aquele verde" e RENAN responde que sim. "Rafael" diz que teria "dinheiro" apenas para "sexta que vem", e RENAN concorda. Em seguida "Rafael" pede "25g"; Em 20/01/21: o contato "Preto" diz a RENAN "Mas se aparecer um trampo eu faço e pego um cha com vc". E em 02/03/21, RENAN afirma ao contato "Preto" que "ta tenho um bomzin ein", e depois diz "e levo um pratu experimenta"; Em 21/01/21: o contato "Bruno Irmão" diz RENAN "O Thyago quer pegar um beck", RENAN pergunta "Quantos", e "Bruno Irmão" diz "Vou passar seu numero para ele fecho".

Não há dúvida, portanto, de que o réu negociava ilicitamente os entorpecentes. Ele mesmo declarou em seu interrogatório nunca conseguiu concluir nenhuma venda porque o seu fornecedor não tinha o entorpecente no momento e depois o comprador não queria mais, deixando claro que os adquiria com o fim de venda, mas depois, segundo ele, não conseguia concluir o comércio (o que não prejudica a conduta "vender", como acima exposto).

A droga com ele apreendida (fls.121), embora num primeiro momento indicasse o fim de uso próprio, teve sua finalidade dubitada a partir da análise das conversas extraídas do celular apreendido.

Certo é que o réu admitiu adquirir entorpecentes com a finalidade de comercialização e efetivamente vendê-los à terceiros, ainda que em pouca quantidade.

Na espécie, pois, o réu incorreu na figura típica, de adquirir, vender, fornecer e ter em depósito, o que ficou materializado pelas conversas constantes do laudo de fls. 367/389, pelo auto de apreensão de fls. 121, pelo exame químico toxicológico de fls. 254/256 e pelo interrogatório em juízo.

Ante o exame de prova oral, bem como todos os fatores circunstanciais que constam aos autos, denota-se que há prova robusta capaz de alicerçar a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Em que pese a confissão do réu quanto à condição de usuário, de se destacar que eventual condição de uso, não exclui a de traficante. Assim, na hipótese, resta inviável o reconhecimento do crime de posse de entorpecentes para fins de uso. Neste sentido o reiterado entendimento dos tribunais pátrios, dentre eles o do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que o simples fato de ser o acusado usuário de drogas não afasta, por si só, sua condição de traficante, desde que existam nos autos elementos probatórios nesse sentido. Aliás, a prática forense tem revelado que não é raro o usuário praticar o tráfico, até mesmo como forma de sustentar seu vício.

Diante desse quadro probatório, inviável falar-se em absolvição, como pretende a defesa do acusado em alegações finais, porquanto restaram suficientemente provadas a autoria e materialidade delitivas atribuídas ao réu pois, ainda que o específico entorpecente apreendido fosse eventualmente direcionado ao uso, restou comprovado que praticava o crime mais grave, justamente para sustentar o vício, o que absorve o crime menor, de mero uso. Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Considero, por fim, a incidência da causa de diminuição prevista no art.33, §4º, da Lei nº 11343/06, eis que no caso em tela, o acusado é primário e não restou demonstrado ser integrante de organização criminosa ou se dedicar constantemente a

atividades criminosas.

Assim, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal, bem como a autoria delitiva, passo a individualizar as penas, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, observo a Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; ostenta bons antecedentes criminais, conforme se infere da certidão de fl.562; à falta de dados desabonadores, considero normal a conduta social; sem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias normais; as consequências são desconhecidas, por não se possuir parâmetros a respeito da quantidade de pessoas atingidas; não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Destarte, à vista de tais circunstâncias judiciais e da valoração negativa de antecedentes e circunstâncias fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes a serem ponderadas.

Na terceira fase, nos termos acima delineados, em atenção à previsão do §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, ante a natureza e quantidade de droga apreendida (10,1g de "maconha" - fls. 121 e 254/256) faço incidir a diminuição de 2/5, razão pela qual fixo a pena definitiva 3 (três) anos de reclusão e 300(trezentos) dias-multa. Nos termos do art. 33, §2º, do CP, considerando a pena definitiva e as circunstâncias judiciais valoradas na fixação da pena-base, fixo o REGIME ABERTO. Deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP.

Tendo em conta que o acusado, pessoa primária, está sendo condenado em razão da prática de crime doloso praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, ao cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, entendo que estão preenchidos os requisitos reclamados pelo art. 44 do Código Penal para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Assim sendo, atento ao fato que a quantidade da pena privativa de liberdade imposta é superior a um ano, substituo-a por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte), consistentes em: prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, em favor de instituição a ser designada pelo Juízo das Execuções, e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para ABSOLVER RENAN DIAS FRANCISCO do crime previsto no art. 286 do Código Penal, com base no art. 386, III, do CPP e CONDENAR RENAN DIAS FRANCISCO como incurso no artigo 33, caput da Lei Federal 11.343/06, à 3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 300(trezentos) dias-multa, substituída a pena privativa liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, em favor de instituição a ser designada pelo Juízo das Execuções, e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante à inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração. Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 12º da Lei 1060/ 1950.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que assim respondeu ao processo, não existindo motivos que justifiquem a decretação da prisão preventiva neste momento.

Declaro perdidos os objetos apreendidos que não forem reclamados por terceiro de boa-fé, em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006

Após o trânsito em julgado da presente ação criminal: Autorizo a incineração da substância entorpecente até então guardada para contraprova; Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional

Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Presidente Eptacio, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA